



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9ª Câmara Criminal Extraordinária

Nº de ordem do processo na sessão de julgamento Não informado

Registro: 2017.0000801930

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0005806-30.2003.8.26.0028, da Comarca de Aparecida, em que é apelante MIQUEIAS VIEIRA LEMES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.

ACORDAM, em 9ª Câmara Criminal Extraordinária do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram as matérias preliminares, porém, nos termos do voto, deram provimento ao recurso para absolver o apelante por insuficiência de provas (art. 386, VII do Cód. de Processo Penal). V.U. Compareceu o Dr. Marino Soares de Souza.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÉRGIO COELHO (Presidente sem voto), AMARO THOMÉ E ALBERTO ANDERSON FILHO.

São Paulo, 20 de outubro de 2017.

Costabile e Solimene
RELATOR
Assinatura Eletrônica



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9ª Câmara Criminal Extraordinária

Apel. n. 0005806-30.2003.8.26.0028
Apelante: Miqueias Vieira Lemes
Apelado: Ministério Público do Est. de S. Paulo
Assistente de acusação: a mãe da vítima
Comarca: Aparecida
2ª Vara Judicial
Voto 36.131

- Processo Penal. Pedido para que seja realizado novo interrogatório. Impossibilidade. A alteração legislativa proveniente da lei 11.719, de 20.6.2008, que inverteu o ato de interrogatório, *per se*, não autoriza a repetição do ato. Precedentes do col. STF e do e. STJ.

- Processo Penal. Intimação para as audiências realizadas noutras comarcas via cartas precatórias. Descabimento. E firme a orientação pretoriana de que ao juízo deprecante apenas compete cientificar a defesa da expedição das cartas. Daí em diante a responsabilidade é dela, parte.

- Processo Penal. Identidade física do MM Juiz. Se se verifica uma das hipóteses do art. 132 do CPC de 1973, não se há falar em vinculação do juiz ao processo. Sentença editada por magistrado que substituiu colega reconhecidamente transferido. Possibilidade de julgamento pelo MM Juiz que substituiu o colega retirado. Precedentes.

- Art. 214 do CP. Denúncia que expressamente remete à suposta violência real. Duração excessiva da instrução. Vítima, filha do apelante, que alcançou a maioria no curso do processo. Incidência do verbete 608 do col. STF. Hipótese de ação penal pública incondicionada. Irrelevância acerca de suposto vício no mandato outorgado para o patrono do assistente.

- *Reformatio in peius* indireta. Se nulificada a antecedente condenação monocrática, uma vez ausente apelo ministerial, não pode o MM Juiz, por ocasião do segundo julgamento, agravar a situação do

**PODER JUDICIÁRIO****TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO****9ª Câmara Criminal Extraordinária**

acusado. Tema que perdeu importância em razão do resultado de mérito, absolvição.

- Atentado violento ao pudor. Pai que teria introduzido dedo na vagina e no ânus da filha de 5 anos. Fato que antecedeu de muito a vigência da lei 12.015, de 7.8.2009. Condenação monocrática. Reforma. Incerteza da prova. Absolvição com base no art. 386, VII do CPP. Crise familiar antecedente, que precedeu mesmo a *notitia criminis*, com separação de corpos entre genitora biológica, ora assistente, e o acusado. Boas referências ao apelante, na condição de pai, não só da genitora da menor, como dos sogros deste. Ademais, laudo negativo a respeito das lesões, efetuado poucos dias após a comunicação das faltas.

- Inadmissível, data vênia, a prolação de decreto condenatório se suficientes os elementos probatórios apenas para fundar suspeitas em face do réu. A simples probabilidade de autoria, tratando-se de mera etapa da verdade, por si só não constitui certeza.

- Preliminares rejeitadas, apelo provido para absolver o apelante por insuficiência de provas.

R E L A T Ó R I O

Na origem o apelante foi condenado a cumprir, a partir do regime fechado, 25 anos de reclusão por conta de pretensamente violar o disposto nos arts. 214 *caput* c.c. 224, a, 225, §1º, II e 226, II e III do Cód. Penal, em concurso material, quando, então, observa-se, foi decretada a sua prisão preventiva (fls. 664/675).

Porém, não resignado, apelou (fls. 699/704 e 705/756).



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9ª Câmara Criminal Extraordinária

Preliminarmente, alegou que a r. sentença seria nula, porque: a) não foi interrogado após as oitivas das testemunhas, assim pretensamente violado o art. 400 do Cód. de Processo Penal; b) não foi notificado para apresentação de defesa prévia, assim também supostamente violado o art. 514 do Cód. de Processo Penal; c) não foi intimado das datas para as oitivas das testemunhas vias cartas precatórias, vide fls. 283/285, 286/288, 192/195, 212/213, 134/135 e 166/vº (ordem dele em sua apelação), assim igualmente violados os arts. 564, I, III e IV e 573 e §§, do Cód. de Processo Penal; d) como a segunda r. sentença foi exarada por outro julgador, que não a MM Juíza, autora da primeira r. sentença, em tese violou-se o princípio da identidade física do Juiz, em contradição com o disposto no art. 399 do Cód. de Processo Penal; e) houve defeso agravamento da r. sentença, se considerada a pena corporal posta na primeira r. sentença (anulada neste e. Tribunal de Justiça), dado que aquele primeiro julgamento balizaria o teto para a nova decisão, assim operando-se a *reformatio in peius* indireta; f) teriam sido violados os preceitos do contraditório e da ampla defesa quando, retornando o laudo pericial realizado por ocasião do incidente de verificação de insanidade, ao qual foi submetido o apelante, este não só não foi interrogado, como sequer lhe oportunizaram alegações finais, assim eventualmente desatendido o disposto no art. 5º, LV da Const. Federal; g) a esta altura, a vítima, maior e capaz, não se achando devidamente representada nos autos, não ratificou o mandato de fls. 201/206 e a procuração de fl. 266, considerando que anteriormente era menor de idade e, por isso, então, aquela representação processual deveria ter tomado forma pública, também inexistente autorização judicial para que os assistentes figurassem no feito (cf. posto a fl. 709), violado, desse



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9ª Câmara Criminal Extraordinária

modo, o disposto no art. 24 do Cód. de Processo Penal.

No mérito, destacando descompassos nas provas documentais e orais, debita todo o acontecido à alienação parental que imputa não só à ex-mulher como também à sogra, dado que teriam engendrado o acontecido em razão dele, apelante, estar trabalhando longe de casa e, para morar com ambas, precisar apartá-las de sua família estendida.

Sem prejuízo, correu a destacar pontualmente um rol de incongruências nas falas das testemunhas acusatórias, a autorizar, face as incertezas, o correspondente *non liquet*.

O apelado e a assistente de acusação formularam suas contrarrazões (fls. 764/767 e 771/789), não passando despercebido que esta última, via embargos declaratórios, questionou o processamento do recurso porque interposto a destempo, dados os problemas de saúde do patrono, o que foi expressamente refutado em 1º grau, sem questionamento recursal (fls. 791/795).

A d. Procuradoria Geral de Justiça deu parecer pelo provimento



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9ª Câmara Criminal Extraordinária

parcial do apelo, para ver adaptada a pena àquela anteriormente imposta, quando exarada a primeira r. sentença, a mesma que restou anulada neste Sodalício (fls. 802/807).

O feito foi originariamente distribuído à e. 15ª Câm. de Direito Criminal, na cadeira do e. Des. Poças Leitão, mas acabou redistribuído para este subscritor, em 2.6.2017, por conta da criação da 9ª Câm. Criminal Extraordinária (fls. 801, 808 e 809).

V O T O N. 36.131

-1-

A denúncia dá conta de que, nos idos de 2001 e 2002, o apelante teria introduzido o dedo tanto na vagina quanto no ânus da própria filha, Arielle dos S. L., então com 5 anos de idade, quando então moravam na av. Padroeira do Brasil n. 224, Aparecida, bem como no estado de Goiás.

E o fez sem olvidar tampar a boca da criança quando esta



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9ª Câmara Criminal Extraordinária

chorava de dor.

Não bastasse isso, se masturbava e ejaculava na frente da pequenina.

-2-

Cf. consta de fls. 499/511, na origem, em 23.12.2009, o apelante foi condenado a cumprir 15 anos de reclusão, a partir do regime fechado, a pretexto de ter violado o contido nos arts. 214 (por 2 vezes) c.c. 224, a, 225, §1º, II, 226, II e III, na forma do art. 69, todos do Cód. Penal.

Não resignado, com sucesso apelou para o e. Tribunal de Justiça, que anulou a r. sentença porque S. Exa., a MM Juíza, não enfrentou todas as matérias preliminares deduzidas pela defesa (fls. 632/636).

E retornando os autos ao 1º grau, ali exarou-se despacho



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9ª Câmara Criminal Extraordinária

consignando que, antes do refazimento da sentença, era caso de chamar o exame de verificação de insanidade ao qual submetido o apelante para os autos (apenso ao 1º volume).

Isso fez demorar a solução do processo e quando o laudo em questão (fls. 100/102 do apenso ao 1º volume) aportou aos autos (a fl. 661 do feito principal), foi exarado despacho para que se desse vistas da prova acrescida às partes, tendo a defesa, inclusive, expressamente se pronunciado pela homologação e acolhimento da perícia em comento (fls. 108/119 do apenso ao 1º volume).

Após tais providências os autos em tela retornaram às mãos do MM Juiz, que, novamente, após estudá-los, condenou o apelante, agora a 25 anos de reclusão, sempre a começar do regime fechado, mais a decretação de sua prisão preventiva (cf. fls. 664/675).

Ausente recurso da assistência de acusação, e mesmo do *Parquet*, está superada a questão atinente à tempestividade do apelo, provada a força maior que levou o patrono ao atraso.

Aliás, com relação a este tema, por analogia, igualmente é

Apelação nº 0005806-30.2003.8.26.0028



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9ª Câmara Criminal Extraordinária

oportuno aqui mencionar o REsp 1.112.864/MG, da Corte Especial do E. Superior Tribunal de Justiça, em que rel. Min. Laurita Vaz, DJe 17.12.2014, RMP vol. 55 p. 443, recurso repetitivo, tema 552, *verbis*:

“(…) Em se tratando de prazos, o intérprete, sempre que possível, deve orientar-se pela exegese mais liberal, atento às tendências do processo civil contemporâneo - calcado nos princípios da efetividade e da instrumentalidade - e à advertência da doutrina de que as sutilezas da lei nunca devem servir para impedir o exercício de um direito (REsp 11.834/PB, Rel. Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, 4ª turma, julgado em 17/12/1991, DJ 30/03/1992) (…)

-3-

Quanto ao mais, rejeito as matérias preliminares cf. adiante justifico.

A vítima, ao tempo dos fatos, contava 5 anos de idade, portanto, a infração era pública incondicionada, mesmo porque o



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9ª Câmara Criminal Extraordinária

suposto agressor era o próprio genitor e a exordial reporta emprego de suposta violência real.

A jurisprudência já indicava há tempos esse caminho, confira-se:

“(…) Em se tratando de estupro ou atentado violento ao pudor cometido com abuso de pátrio poder, procede-se mediante ação penal pública incondicionada, não havendo falar, em casos tais, em decadência do direito de representação da vítima. Inteligência do artigo 225, parágrafo 1º, inciso II, do Código Penal)” (STJ, HC 69.198/SP, rel. Min. Hamilton Carvalhido, DJe 22.4.2008).

A orientação acima fez coro, leia-se a respeito os mais outros julgados identificados a seguir: STJ, HC 69.666/SP, REsp 660.042/SC e REsp 141.622/GO.

Nos termos do art. 225, § 1º, inciso II, do CP, no caso de crime contra a dignidade sexual, cometido com abuso do pátrio poder, a ação penal é pública incondicionada, não cabendo falar-se em decadência do direito de representação ou de queixa.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9ª Câmara Criminal Extraordinária

Sem prejuízo, como retro destacado, a exordial ainda dá conta de violência real (penetração com o dedo da vagina e do ânus), então, também por tal motivo, dispensável representação, evidentemente incidente o verbete 608 do col. Pretório Excelso, *verbis*:

“No crime de estupro, praticado mediante violência real, a ação penal é pública incondicionada”.

Cf. posto no relatório, a circunstância de a solução do processo demorar não obriga a vítima a ratificar a vontade de processar o pai ou mesmo de trazer patronos via mandato, este último agora exarado em consonância com sua plena capacidade, repito, dada a natureza da ação penal reconhecida pelas circunstâncias já mencionadas, fixada a sua natureza no momento da infração e por se ter exercido o abuso supostamente com violência real.

E, é fato, ainda que assim não fosse, não se reconheceria vício algum, eis que não há falar em prejuízo para o acusado, considerando as peculiaridades processuais retro explanadas. Sem a demonstração de efetivo dano à defesa do apelante incide o princípio maior que rege o tema, segundo o qual, sem prejuízo, não se reconhece a nulidade, a teor do art. 563 do Código de



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9ª Câmara Criminal Extraordinária

Processo Penal.

Agregamos a tal contexto mais outro argumento, de que o legislador ainda acolheu o princípio de conservação de forma expressa, que se traduz no não reconhecimento da nulidade ausente prejuízo, ainda que existente vício, pois é exatamente disso que trata a redação do art. 566 do Cód. de Processo Penal:

“Não será declarada a nulidade de ato processual que não houver influído na apuração da verdade substancial ou na decisão da causa”.

Ora, sendo a ação pública incondicionada, se a jovem hoje é maior e capaz, qual o prejuízo a não ratificação nesta quadra, se a verificação da legitimação do Ministério Público se dá no momento da falta, quando muito no momento da oferta da denúncia?

Lê-se na própria “Exposição de Motivos do Código de Processo Penal”, item XVII, que “não será declarada a nulidade de nenhum ato processual, quando este não haja influído concretamente na decisão da causa ou na apuração da verdade substancial. Somente



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9ª Câmara Criminal Extraordinária

em casos excepcionais é declarada insanável a nulidade”.

Quanto ao mais, consigno que, interrogado na audiência de fl. 116, declinou o nome de sua então patrona, que realmente foi intimada para a 1ª audiência, não tendo comparecido (fl. 123). Nesta ocasião determinou-se a expedição de cartas precatórias para produção de prova oral fora da comarca, expressa a cientificação da causídica para tal mister, como, aliás, também foi comunicada inclusive via imprensa oficial (fls. 129, 136 e 141).

Ora, consoante posto na lei e na jurisprudência, o Advogado tem direito de saber da expedição das cartas precatórias, mas, daí em diante, a ele cabe acompanhar o processo no juízo deprecado, bem como se informar sobre a data designada para a audiência de instrução. Deveras, “Não há nulidade a ser declarada quando não ocorre intimação para a audiência de oitiva de testemunha na comarca deprecada, por inexistência de previsão legal. À parte cabe acompanhar o cumprimento de precatória, inclusive os seus incidentes” (STF, 2ª T., HC 79.446-7/SP, rel. Min. Maurício Corrêa, DJU de 26/11/99 ou RT, 774/518).

Nesse sentir há mais outro aresto do mesmo Pretório Excelso, a evidenciar que a questão está pacificada:



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9ª Câmara Criminal Extraordinária

“A ausência de intimação para a oitiva de testemunhas no juízo deprecado não consubstancia nulidade (precedentes). Havendo ciência da expedição da carta precatória, como no caso, cabe ao paciente ou a seu defensor acompanhar o andamento no juízo deprecado. Ordem denegada” (STF, 2ª T., HC 89.159-4/SP, rel. Min. Eros Grau, LexSTF, 338/440, ou RT, 856/517).

Em outras palavras, “Expedida carta precatória para oitiva de testemunha, do que se deu ciência à defesa, competia a esta saber do dia e horário de seu depoimento, não havendo dispositivo que determine a sua intimação, desse ato, pelo juízo deprecado” (STJ, 6ª T., REsp 126.046/MG, rel. Min. Anselmo Santiago, DJU de 10/08/98, pág. 91 ou RSTJ, 159/690).

A jurisprudência, sobre tal assunto, acha-se consolidada também noutras instâncias (cf., p. ex., RTJ, 95/547, 139/519, 141/556, 181/727 e 195/583; RSTJ, 32/110 e 76/68; LexJTJ, 174/333-4, 176/310, 188/311, 233/368 e 238/358; RJDTCrim, 5/130, 27/158 e 30/406; RJTJERS, 149/144; JCat, 62/244 RT, 487/295, 493/347, 500/342, 525/352, 536/370, 569/289, 610/375; 681/335, 716/517, 730/480, 760/710-1, 763/573, 769/694, 803/575 e 819/545).

Tanto que existe a Súmula n. 273 e cujo enunciado



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9ª Câmara Criminal Extraordinária

expressamente dispõe:

“Intimada a defesa da expedição da carta precatória, torna-se desnecessária intimação da data da audiência no juízo deprecado”.

A propósito, sua patrona, aquela por ele formalmente indicada logo que começou o contraditório, apresentou sim defesa prévia, por sinal, no momento então adequado considerando a legislação da época (fls. 100/101), indicando endereços de outras comarcas, de sorte que não poderia alegar desconhecimento da massiva jurisprudência retro transcrita e das implicações processuais acerca da convocação e oitivas daquelas fontes que eram moradoras noutras cidades.

No mais, também observo que a alteração processual que trouxe o interrogatório para o final da instrução deu-se com o advento da lei 11.719, de 20.6.2008, ou seja, muito depois daquele ato transcrito a fls. 111vº e 116/118, levado a cabo em Pindamonhangaba ainda em 28.9.2005. De sorte que não só não há se falar em repetição do interrogatório, eis que praticado em consonância com a lei do seu tempo, como presente no processo a correspondente defesa prévia, inviável a repetição da oportunidade só porque a r. primeira sentença foi anulada. E anulada



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9ª Câmara Criminal Extraordinária

especificamente por não abordagem das preliminares sem ordem de refazimento da instrução.

Novamente consoante jurisprudência do col. Supremo Tribunal Federal e do e. Superior Tribunal de Justiça, “é válido o interrogatório do réu realizado antes da vigência da Lei n. 11.719/2008, que alterou o art. 400 do CPP, e a falta de renovação do interrogatório como último ato de instrução processual não implica nulidade do processo, pois houve o cumprimento da legislação anterior, à luz da regra *tempus regit actum* (art. 2º do CPP)”.

Isso se acha devidamente expresso nos seguintes julgados: STF, HC n. 123.228, rel. Ministra Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 25/9/2015 e STJ, REsp 1.340.710/RS, rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe 17.11.2016.

Durante suas perorações, ainda no âmbito do recurso de apelação, o e. Defensor admitiu que a MM Juíza que prolatou a r. sentença anulada neste Tribunal foi transferida de comarca ao tempo da edição da segunda sentença (vide fls. 711/712). Aqui, ao tempo da instrução, incidia o quanto posto no art. 132 do Cód. de Processo Civil, ou seja, “O juiz, titular ou substituto, que



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9ª Câmara Criminal Extraordinária

concluir a audiência julgará a lide, salvo se estiver convocado, licenciado, afastado por qualquer motivo, promovido ou aposentado, casos em que passará os autos ao seu sucessor”.

Nesta quadra, então, pareceu-nos, a título de reforço de argumentação, oportuno invocar o magistério de Nelson Nery Júnior, em obra conjunta com Rosa Maria Andrade Nery, quando discorreram sobre o tema em questão ("Código de Processo Civil Comentado", pág. 392, nota 5, ed. Revista dos Tribunais, 10ª edição). Confira-se a lição:

“Mesmo que tenha concluído a audiência, o magistrado não terá o dever de julgar a lide se for afastado do órgão judicial por motivo de convocação, licença, cessação de designação para funcionar na vara; remoção, transferência, afastamento por qualquer motivo, promoção ou aposentadoria. Incluem-se na exceção os afastamentos por férias (grifo do relator), licença-prêmio e para exercer cargo administrativo em órgão do Poder Judiciário (Assessor, Juiz Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça etc)”.

Assim sendo, respeitosamente, mesmo em homenagem ao espírito da celeridade contido no art. 5º, inc. LXXVIII da



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9ª Câmara Criminal Extraordinária

Constituição Federal, nada desautorizava o MM Juiz que prolatou a r. sentença de fazê-lo, já que substituiu a e. julgadora transferida. Ademais, se caso fosse, competiria ao apelante invocar hipótese não contemplada nas exceções ao aludido princípio da identidade física do juiz e nesse mesmo sentir o aresto do E. Superior Tribunal de Justiça:

“(…) No caso em apreço, não obstante já estivesse em vigor o § 2º do art. 399 do Código de Processo Penal quando da prolação da sentença, não há qualquer informação nos autos do motivo pelo qual o édito repressivo foi exarado pela Juíza (...) e não pelo magistrado que presidiu a instrução do processo, qual seja, Dr. (...), razão pela qual não há como se aferir se o presente caso enquadra-se nas exceções ao princípio da identidade física do juiz preconizadas no art. 132 do Código de Processo Civil a ensejar ou não o reconhecimento da aventada nulidade da decisão condenatória. (...) 3. Ordem denegada. (HC 133407/RS, 2009.0065685-5, rel. Min. Jorge Mussi, julgado em 03/02/2011, v.u).

Finalmente, a defesa reclama que, uma vez juntado o laudo que rechaçou incapacidade mental, ao réu não foi assinalado prazo para apresentar suas alegações finais, assim supostamente violado o disposto no art. 5º da Const. Federal, inciso LV.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9ª Câmara Criminal Extraordinária

Mais uma vez sem razão, por conta de que o retorno dos autos à 1ª instância foi determinado para realização de novo julgamento, examinando-se, então, objetivamente as matérias preliminares.

Todavia, quando os autos se achavam em mãos do MM Juiz, este também verificou a ausência do laudo de conferência de eventual incapacidade do increpado, pelo que determinou a sua juntada, o que atrasou a solução do processo. Mas, uma vez trazido o sobredito exame médico para o apenso respectivo, sobre ele a defesa teve sim, ainda que no mencionado apenso, oportunidade para comentar a prova, o que, aliás, acabou sendo objetivamente feito em 19.12.2014 (fls. 108/119). Por sinal, expressamente concordou com as conclusões do perito, de modos que não mais seria necessária repetição de mais outro ato de igual substância, só para ser juntado no feito principal.

-4-

Duas questões, ainda que tratadas pelo apelante como causas de nulidades, em razão de peculiaridades que destacarei no momento oportuno, deverão ser abordadas. Estou me referindo tanto (i) à validade (ou não) do relatório psicológico realizado sobre as personagens do fato em comento, e tido pela defesa



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9ª Câmara Criminal Extraordinária

como supostamente adulterado, apresentado em duplicidade e dado como sem as devidas cautelas processuais, bem como à (ii) extrapolação das penas corporais postas na primeira sentença, sentença aquela que restou anulada.

No que diz respeito a este último tópico, a reclusão de 15 anos, por ocasião do segundo título judicial, subiu para 25 anos, contra o que a parte se insurgiu.

E por causa disso aqui se mostrou adequado invocar o escólio do e. Des. Guilherme de Souza Nucci, quando ensina a respeito da *reformatio in pejus* indireta:

“(...) trata-se da anulação da sentença, por recurso exclusivo do réu, vindo outra a ser proferida, devendo (o MM Juiz) respeitar os limites da primeira, sem poder agravar a situação do acusado” (Cód. de Processo Penal Comentado, 13ª ed., Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 1.164).

Também nos termos do pacífico entendimento do e. Superior Tribunal de Justiça, “resta evidenciada a ocorrência de



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9ª Câmara Criminal Extraordinária

reformatio in pejus quando, em recurso exclusivo da defesa, a situação do réu é agravada pela majoração da pena anteriormente aplicada” (HC 317.163/SC, rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 19.12.2016).

O assunto já se acha superado por jurisprudência consolidada, veja-se de igual teor sempre naquela Corte Superior mais estes julgados: HC 204.853/SP, HC 134.686/SP, HC 203.820/SP e HC 147.736/SP.

Ora, porque anulado o julgamento monocrático, quando da apelação criminal conhecida por esta Corte, o MM Juiz não poderia, ao realizar o segundo julgamento, aumentar a pena fixada no primeiro julgamento. E, se assim procedeu, cf. escólios antes aqui destacados, incorreu em inadmissível *reformatio in pejus* indireta.

Evidenciou-se, pois, que a r. sentença alvo desta apelação esbarrou no texto do art. 617 do Cód. de Processo Penal, por isso, se caso fosse, haveríamos de promover a adequação levando em conta o resultado menos desfavorável ao apelante. Noutras palavras, se houvesse condenação seria balizada pela 1ª condenação.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9ª Câmara Criminal Extraordinária

O problema do laudo, trazido à colação pela defesa, deve ser superado pois serviu de informativo aos julgadores, a cruzar com os demais dados dos autos, em especial o laudo psiquiátrico negativo ao qual submetido o increpado no final da instrução. É matéria de mérito e não de processo, por dizer respeito à prova.

-5-

E, contudo, quanto ao mérito, preservados os elevados convencimentos dos MM Juízes, estou propondo, à e. turma julgadora, a reforma do resultado para, com base no art. 386, VII do Cód. de Processo Penal, julgar improcedente a ação em curso, pese esta demanda, por duas vezes, ter sido superiormente julgada na jurisdição de piso contra o apelante e com sanções corporais de vulto.

É que, lendo as duas r. sentenças retro referidas, nos foi dado ver que os d. Magistrados, sobremaneira, prestigiaram as palavras da pequena vítima (alvo do que seria um delito clandestino), aquelas, por sinal, respaldadas por sua mãe e sua avó.

Todavia, sem desmerecer aquelas fontes, abrimos aqui



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9ª Câmara Criminal Extraordinária

parênteses para invocação da hermenêutica probatória, tema essencialmente relevante em razão de peculiaridades da presente ocorrência.

Convenhamos, de plano, não se poder descartar o testemunho infantil só por tal circunstância, mas, como em tudo do processo penal, o mesmo obrigatoriamente tem de ser avaliado em conjunto com o mais das provas, como assim predicam os julgados a saber: TJSP, Revisão Criminal n. 0253683-51.2012.8.26.0000, rel. Des. Otávio Henrique, 5º Grupo de Direito Criminal, J. 8.5.2014 e TJSP, Apel. n. 0016094-48.2003.8.26.0477, rel. Des. César Augusto Andrade de Castro, 4ª Câmb. Criminal Extraordinária, J. 27.3.2014.

Demais disso, é igualmente imprescindível que o contexto acusatório seja firme, incontroverso, pena de imperdoáveis arbitrariedades.

Tais observações se apresentaram oportunas na medida em que, como dito, os fatos nestes autos não contêm testemunhos presenciais, exceto as palavras dos envolvidos, remanescendo por considerar a relevância do exame das palavras da vítima, comumentemente prestigiadas por esta turma recursal, desde



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9ª Câmara Criminal Extraordinária

que, insisto, em sintonia com o mais coligido.

Inicialmente apontamos algumas peculiaridades nas falas da ofendida.

Pese com menos idade, a jovem, ainda na delegacia, foi mais minuciosa quando contou ao Dr. Delegado sobre os fatos, tratando não apenas das várias penetrações imputadas ao genitor, com o emprego dos dedos, como também sobre a pretensa masturbação.

Todavia, não se ocupou de convencer acerca da demora na revelação das agressões (cerca de um ano), o que se mostrou fora dos padrões da normalidade, inclusive porque os fatos somente vieram à baila depois de o seu genitor, por iniciativa da mãe, ter sido posto para fora de casa, e por outras razões, via ação cautelar de separação de corpos cujas cópias estão no feito.

Em juízo, sua avó, como também o seu avô, deram conta de que jamais tiveram motivos para desconfiar do genitor, expressamente atestando o bom comportamento na condição de pai.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9ª Câmara Criminal Extraordinária

A esposa do réu jamais mencionou qualquer nuance sequer de taras sexuais, tanto que, repito, ao pedir judicialmente a separação de corpos, quase dois meses antes da *notitia criminis* que deu azo a este processo, o fez exclusivamente com base em supostas agressões e no medo de o varão – afastado de casa em razão de compromissos profissionais – resolver que a família haveria de voltar para Goiás.

Ora, convenhamos, se todos os depoentes retro enumerados ocupavam o mesmo imóvel, noutro estado, como mais tarde também em Aparecida, ou seja, réu, esposa, os filhos, a sogra e por um período sua irmã, ficou estranho, lacunoso e inconvincente, não tivessem, quaisquer deles, notado algo diferente na conduta da vítima ou no desempenho social do apelante.

Insisto, tudo somente foi revelado quando houve a separação cautelar do casal e no tempo em que discutiam se se mantinham neste nosso estado, na cidade de Aparecida, ou se retornavam para a sede do trabalho do acusado, então Engenheiro no interior de Goiás.

E não bastasse esse quadro nebuloso, que prejudicou o



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9ª Câmara Criminal Extraordinária

acolhimento das palavras da ofendida – até porque o varão contava com ampla confiança de todos os parentes –, o laudo médico-pericial de fls. 15/verso resultou negativo, importante anotar que o exame foi levado a cabo dias depois da comunicação das agressões, quando então as lesões deveriam se fazer presentes, até porque a menor reclamou de dores agudas para a avó.

Observo que as sobreditas agressões são daquelas que deixam marcas, marcas, porém, nunca materialmente confrontadas. A mãe e a avó, logo após a comunicação, conduziram a menor à presença de um médico (cf. depuseram em juízo), mas nada foi constatado.

Resumindo, pois, nada convence teriam as lesões desaparecido tão rapidamente, especialmente quando – torno a repetir – existe referência no processo de que a menina se manifestava profundamente incomodada, como se uma “agulha” estivesse no interior do seu corpo.

Observo que a comunicação para a autoridade policial deu-se em 25.2.2003 (fl. 5), o exame pericial no corpo da vítima foi realizado dois dias depois, em 27.2 (fl. 15vº), tudo, por sinal,



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9ª Câmara Criminal Extraordinária

menos de sessenta dias desde a distribuição da ação de separação de corpos já mencionada, em Aparecida (em 16.2.2002).

Evidentemente, soubessem do acontecido nos anos anteriores (a exordial remete a 2001 e 2002), parentes não teriam ficado calados. Contariam imediatamente sobre as agressões sexuais à pequenina. A exordial de fls. 413/415, distribuída no juízo cível local, a propósito, como retro apontado, simplesmente silencia sobre isso.

De dezembro de 2002 até o começo de fevereiro do ano seguinte o acusado, que gozava de prestígio junto da mulher e dos genitores desta, que era tido como bom pai, insuscetível de desconfianças, num átimo transformou-se em elemento agressivo, sexualmente comprometido, estuprador de criança.

O proscênio, todavia, ao ver deste subscritor, é por demais inseguro, ainda que o varão tenha admitido que estava com um CD contendo filme proibido, pornográfico, indicador, porém, isolado e por tal minúcia não relevante para o resultado final, até porque foi explicada a sua posse (seria de um amigo em mudança).



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9ª Câmara Criminal Extraordinária

A mulher que o acusa também deu conta de ter visto em seu computador mais material pornográfico, dando azo à apreensão policial do equipamento, que, no entanto, levado à perícia, sobre o assunto nele também nada foi localizado sobre o tema (fls. 33/34).

De se convir que é especial a natureza dos atos descritos na exordial, peculiares a alguém que deveria exibir outro perfil psicológico, não aquele inicialmente descrito pelas testemunhas de acusação (bom pai, insuspeito).

Na medida em que o fato em discussão teria sido clandestino, tomaram relevância as menções feitas por outras das fontes, que acompanharam a ocorrência, especialmente aqueles que partilhavam de sua intimidade, repito, o seu sogro, a sua sogra e a sua ex-mulher.

Antes da colocação profissional em Goiás, antes da distância de casa para atender aqueles compromissos de trabalho, antes dos entreveros que obstaram o retorno do núcleo familiar ao Brasil central, nada fora aventado, só surgindo as graves acusações em meio às deliberações sobre o futuro de sua família.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9ª Câmara Criminal Extraordinária

Respeitosamente, isso fragilizou sobremaneira as provas indiciárias.

O laudo pericial não confirma o que foi contado às autoridades policiais, não revela o cerne da denúncia ministerial. Não há constatação das lesões. Sobre o passado igualmente nenhuma referência. Não houve apreensão de pornografia e o varão buscou obter autorização judicial para visitar a prole. Isso tudo não pode ser desconsiderado.

Mesmo o respeitável estudo psicológico perdeu destaque, porque evidenciado conflito com o resultado do laudo colhido no incidente de verificação de insanidade mental (fls. 100/101 ao apenso do 1º volume). O médico psiquiatra não destacou qualquer transtorno de comportamento. Deu o apelante como alguém plenamente capaz, sem indicar nenhum sinal de desvio de conduta.

Ou seja, data vênua, a prova coligida não se mostrou satisfatória para resultar numa condenação, quanto mais esta de vulto.

Se a versão defensiva não deve ser acolhida em sua plenitude,



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9ª Câmara Criminal Extraordinária

de todo o modo, não temos como descartá-la. Na dúvida, há de se presumir a inocência do condenado¹. Cf. Malatesta², citado na mesma revista de jurisprudência por Azevedo Franceschini, “a certeza, como estado subjetivo do espírito, obviamente pode não corresponder à verdade objetiva”. Isso também quer dizer que nem tudo que os olhos contemplam pode essencialmente conter a verdade.

O comentário é oportuno, porque a antipatia por quem é acusado de tais infrações é peculiar a qualquer cidadão, não, contudo, ao Juiz, que somente pode condenar se a prova é inconteste, certa e presente no interior do processo.

Noutras palavras, para determinada pessoa a prova de certo processo é enfocada como suficiente de molde a embasar decreto condenatório; para outra, ao contrário, a mesma prova poderá se apresentar precária, conduzindo para solução diversa, qual seja, a absolvição, então sendo difícil o real significado da efetiva contrariedade à “evidência dos autos”.

Mesmo em segunda instância essa realidade encontra

¹ Ou seja, *in dubio pro libertate* - na dúvida, pela liberdade. No mesmo diapasão, *libertas omnibus rebus favorabilior est* - em todas as coisas, a liberdade é mais favorecida, ou deve receber o maior favor, cf. tradição romana.

² “A Lógica das Provas em Matéria Criminal, 2ª ed., p. 21



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9ª Câmara Criminal Extraordinária

ressonância nos acórdãos não-unânicos, daí porque, em situações deste jaez, é preciso a convocação de outros juizes da Câmara Criminal, para estudo de eventuais embargos infringentes, de sorte a obter definição do julgamento, em cuja sessão poderá ainda ocorrer nova divergência, até mesmo entre os dois novos integrantes da turma julgadora, sendo possível reformulação de posicionamento antes assumido, à vista de novos argumentos trazidos.

O processo penal, isso é patente, somente se satisfaz com a certeza plena.

No caso em tela, pese a jovem ter increpado o genitor, jamais deu notícia do ocorrido, a não ser quando evidenciado o interesse materno em permanecer no estado de S. Paulo, noutras palavras, não acompanhar o marido para Goiás. Somente nesse momento é que surgiu um novo perfil, de pessoa agressiva, com conotação sexual desviada, a ponto de, repetidamente, introduzir o dedo na genitália da menor, sua filhinha.

Porém, salvo melhor juízo, ninguém muda radicalmente de comportamento sem pré-aviso e de modo tão rápido, como sugerido no caso em comento.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9ª Câmara Criminal Extraordinária

Ademais, temos sim prestigiado a palavra da vítima, mas quando ela se acha em conformidade com o contexto, o que não é a hipótese.

A criança, na delegacia, revelou que o apelante ameaçou “bater em sua cara” se contasse sobre o acontecido (fl. 6), sendo que ao MM Juiz a ameaça era outra, qual seja, de morte (fl. 269). Também ressaltou que o pai – suposto portador de anormalidades – “nunca fez nada com a irmã mais nova” (fl. 270 in limine). Por sua feita, esta irmã mais nova, quando das agressões, estaria acordada (declarações em juízo, a fl. 269), versão diferente contada à autoridade policial: “Gabrielli estava no quarto (...) mas dormindo” (*verbis*, fl. 6).

Não bastasse esses descompassos, o apelante sempre gozou de prestígio, de bom juízo junto dos parentes da mulher, que não economizaram afirmativas nesse sentido.

A fls. 272/273 a mãe da menor, d. Daniele Regina, atestou ao d. Magistrado “que sempre confiou nele como pai”, que conviveram por cerca de 6 anos e ele “sempre combateu a pornografia (...)”, tendo, durante sua oitiva em juízo, expressado que “nunca imaginou que ocorresse o fato” (*verbis*).



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9ª Câmara Criminal Extraordinária

O sogro do réu, João Ribeiro (fls. 166/verso), em audiência, deu conta que nunca antes tinha apontado qualquer comportamento suspeito do inculpado, ou seja, nada que o vinculasse a “esse tipo de conduta”.

Mesmo tom é encontrado nas falas de d. Geralda Luiz dos Santos Ribeiro, a avó materna para quem, em 1º lugar, a vítima revelou o acontecido. Referindo-se ao genro literalmente asseverou que “(...) com ele sempre se deu bem (...) nunca notou comportamento diferente dele em relação aos filhos” (fl. 134 *in fine*).

Ou seja, dentro de casa, compartilhando o mesmo espaço, o acusado, sempre tido em boa conta, às costas dos parentes por afinidade, da esposa, estaria torpemente perpetrando agressão contra criança de tenra idade, sua filha biológica, a qual, por sinal, convenhamos, descreveu o acontecido de modo incongruente, se comparadas as falas no inquérito e sob o contraditório.

Não há laudos favoráveis, continuou sua vida profissional, jamais exibiu crueldade, maldade ou sociopatologia, tecnicamente tido por capaz, segundo prova médico-pericial.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9ª Câmara Criminal Extraordinária

Ora, nesta quadra, em razão das lacunas probatórias destacadas, pareceu-nos adequado rememorar que a jurisprudência, via de regra, afirma não ser admissível “a prolação de decreto condenatório se suficientes os elementos probatórios apenas para fundar suspeitas em face do réu”, dado “que a simples probabilidade de autoria, tratando-se de mera etapa da verdade, por si só não constitui certeza” (JUTACRIM 45/218).

Noutras palavras, em matéria de condenação criminal só indícios não bastam, eis que a prova da autoria há de ser concludente, ou seja, estreme de dúvidas, na medida em que apenas a certeza pode autorizar responsabilização penal (RT 708/339).

Também é de se dizer que a prova judiciária, para dar margem a um juízo seguro de reprovação da conduta endereçada a qualquer acusado, com todas as suas conotações possíveis, há de ser conclusiva, mesmo certa, não bastando um forte grau de probabilismo sobre ter determinada pessoa cometido o crime desta ou daquela maneira.

Qualquer outro juízo tirado diferentemente dessa preconizada orientação atine ao campo da probabilidade, exteriorizando incerteza ou dúvida.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9ª Câmara Criminal Extraordinária

E, na dúvida, a melhor solução ainda é julgar-se sempre a favor do réu, pena de cometerem-se as mais esdrúxulas e deslavadas injustiças.

Ante o exposto, rejeito as matérias preliminares, porém, nos termos do voto, dou provimento ao recurso para absolver o apelante por insuficiência de provas (art. 386, VII do Cód. de Processo Penal).

COSTABILE E SOLIMENE, relator